

1502666-87.2021.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2222639/2021 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 19659508 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 4998/21/924 - DEL.SEC.RIO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

1ª Vara Criminal

Avenida 5 nº 545, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502666-87.2021.8.26.0510 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502666-87.2021.8.26.0510

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2222639/2021 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 19659508 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 4998/21/924 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2222639 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2222639 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 4998/21/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIANA GORETTE VIANA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Vistos.

LUCIANA GORETTE VIANA e EDSON LORRAN BEZERRA RAMOS, qualificados nos autos, foram

denunciados como incurso no artigo 33, "caput", e § 1º, inciso I, da Lei nº 11.343/06, c.c. as disposições da Lei nº 8.072/90, assim porque, no dia 16 de agosto de 2021, por volta das 17h00min, no condomínio Vila Verde II, bloco 20, apto 21, Avenida C, nº 255, Chácara Luza, nesta Comarca, LUCIANA GORETTE VIANA, agindo em concurso e com identidade de propósitos com EDSON LORRAN BEZERRA RAMOS, guardava e tinha em depósito, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, 8 (oito) porções, em formato de tijolos, contendo a substância entorpecente denominada cocaína, totalizando peso líquido aproximado de 7.736,1 gramas, além de invólucros plásticos contendo a substância entorpecente denominada tetraidrocanabinol (maconha), totalizando peso líquido aproximado de 236,4 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 21/23, laudo de constatação de fls. 35/38 e laudo toxicológico de fls. 114/117, enquanto na Avenida 12, nº 350, Centro, nesta Comarca, EDSON LORRAN BEZERRA RAMOS, agindo em concurso e com identidade de propósitos com LUCIANA GORETTE VIANA, trazia consigo, guardava e tinha em depósito invólucros plásticos contendo substância que totalizava peso líquido aproximado de 1591,1 gramas, invólucros plásticos contendo substância que totalizava peso líquido aproximado de 38,7 gramas, e microtubos plásticos do tipo eppendorf contendo substância que igualmente totalizava peso líquido aproximado de 4,73 gramas, conforme especificadas nos itens 2, 3 e 4 do laudo de constatação de fls. 35/38, positivadas para cafeína, matéria prima, insumo ou produto químico constante na lista III da Portaria MJ 240/2019, destinado à preparação de drogas, conforme laudo de exame complementar de fls. 173/175, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 194/196).

Regularmente notificados (fls. 216, 218), seguiu-se o oferecimento de defesas preliminares em favor dos acusados (fls. 231/234, 249/259), sendo posteriormente recebida a denúncia no dia 06 de março de 2022 (fls. 277/287).

Em instrução, foram ouvidas quatro testemunhas comuns, seguindo-se os interrogatórios dos acusados (fls. 318).

Em alegações finais, a ilustre Representante do Ministério Público, à vista da prova produzida, requereu a condenação dos acusados, nos termos da denúncia, com fixação das penas-bases nos mínimos legais, majorando-se em razão da reincidência específica de LUCIANA (fls. 315/316) e da reincidência por roubo e furto de EDSON, inviabilizando-se a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, em razão da reincidência e da dedicação ao tráfico em relação a ambos os acusados, fixando-se o regime prisional inicial fechado (fls. 318).

A ilustre Defensora Pública, atuando em favor do acusado EDSON, requereu a absolvição, em síntese porque não houve apreensão de substância entorpecente em poder dele ou na moradia que ocupava (laudos de fls. 166/168, fls. 268/270), sendo localizada tão somente cafeína, não estando a mesma descrita na lista F1 de substâncias de uso proscrito no Brasil, de acordo com a Portaria 344/98, da ANVISA, ou da lista D2 da Portaria 344/98, da ANVISA, não se comprovando que estivesse destinada à produção de drogas, vinculando o acusado com o entorpecente apreendido na residência da corré. Ademais, sustentou ilícita a busca domiciliar e as demais diligências realizadas, já que ocorreram com base em denúncia anônima, não tendo sido cientificado o acusado de seu direito de permanecer em silêncio, havendo também invasão de domicílio, requerendo seja reconhecida a ilicitude da ação, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal, a determinar a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso II, do mesmo Diploma Legal. Sustentou, ainda, insuficiente a prova produzida, já que não apreendido entorpecente em posse do acusado, não tendo sido comprovada a vinculação dele com aquela substância apreendida na moradia de LUCIANA, a ensejar a absolvição, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena base no mínimo legal, possibilitando-se a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, estando ausente a recidiva específica, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação de regime prisional inicial aberto, em caso de reconversão, em observância ao artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal e ao princípio da proporcionalidade, facultando-se a interposição de recurso em liberdade (fls. 318).

A ilustre Defensora da acusada LUCIANA, a sua vez, sustentou nula a prova produzida com a apreensão realizada na moradia da acusada, assim porque derivada da violação do domicílio do corréu EDSON, além de despida de justa causa a diligência policial e maculado o consentimento de ingresso no imóvel, dadas as circunstâncias em que abordada a acusada. Observou, ademais, não evidenciada a autoria, já que a prova produzida ratificou a versão da acusada, tudo a ensejar sua absolvição.

Subsidiariamente, em caso de condenação, pugnou pela fixação da pena base no mínimo legal e regime prisional menos gravoso, reconhecendo o direito de a acusada recorrer em liberdade (fls. 318).

Em síntese, o RELATÓRIO.

DECIDO.

Procede a pretensão acusatória.

Atribui-se aos acusados a prática do delito previsto no artigo 33, "caput", e § 1º, inciso I, da Lei nº 11.343/06, c.c. as disposições da Lei nº 8.072/90, assim porque, nas datas indicadas na denúncia, LUCIANA GORETTE VIANA, agindo em concurso e com identidade de propósitos com o coacusado, guardava e tinha em depósito, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, o entorpecente indicado na denúncia, enquanto EDSON LORRAN BEZERRA RAMOS, também agindo em concurso e com identidade de propósitos com aquela, trazia consigo, guardava e tinha em depósito invólucros plásticos contendo substâncias positivadas para cafeína, matéria prima, insumo ou produto químico constante na lista III da Portaria MJ 240/2019, destinado à preparação de drogas.

A materialidade do delito vem comprovada pelo que exposto no laudo de exame químico-toxicológico encartado as fls. 114/117, com resultado positivo para cocaína e tetrahidrocannabinol, responsável pelos efeitos estupefacientes da maconha, e pelos laudos encartados a fls. 153/155, 166/168, 268/270 com resultado positivo para cafeína.

Sustenta-se que estaria comprometida a apreensão do entorpecente, maculando a materialidade do delito, assim em razão da ilícita abordagem inicial, fundada em denúncia anônima, como também em razão da violação de domicílio.

Entretanto, respeitado o entendimento exposto pelos combativos Defensores, após o recebimento de informação contendo o endereço da moradia do acusado bem como suas características físicas, relacionando-o à prática do tráfico ilícito de entorpecentes, Policiais Militares se dirigiram ao local e o avistaram defronte à moradia, momento em que ele empreendeu fuga, dispensando uma sacola plástica. Após abordado, constatou-se no interior da sacola dispensada uma trouxa contendo substância que aparentava ser cocaína.

Diante destas circunstâncias, com informação que relacionava o acusado ao tráfico, confirmada com a localização dele no local apontado, além da fuga iniciada, jogando ao solo uma sacola com substância assemelhada a cocaína (com indicação posterior de se tratar de insumo para preparação de droga, comumente utilizada), reuniram-se elementos que permitiram vislumbrar, desde logo, o estado flagrancial que excepcionava a garantia de inviolabilidade do domicílio, seguindo-se a apreensão de 34 (tinta e quatro) eppendorfs (capsulas plásticas utilizadas para a venda de cocaína), outros 05 (cinco) pacotes pequenos com substância que se assemelhava a cocaína, além de 501 (quinhentos e um) eppendorfs vazios, uma balança SF-400, um liquidificador sem tampa com sujidades de cor branca, duas colheres e um garfo com sujidades de cor branca, três peneiras com sujidades de cor branca, quatro vasilhas do tipo tupperware sem tampa, com sujidades de cor branca, bem como um rolo de embalagem plástica e uma fita crepe, indicando o acusado, na ocasião, que estava envolvido com o refino e embalo de entorpecente, declinando em seguida o endereço da acusada como responsável pelo armazenamento do entorpecente.

Verificou-se que as substâncias apreendidas em poder do acusado tratavam-se de cafeína, em circunstâncias que demonstram serem insumos para a preparação de entorpecente (cocaína), incidindo o que disposto no artigo 33, § 1º, inciso I, da Lei n. 11.343/06 [art. 33 - Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação

legal ou regulamentar: § 1º - Nas mesmas penas incorre quem: Inciso I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito (grifei), transporta, traz consigo ou guarda (grifei), ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima (grifei), insumo (grifei) ou produto químico destinado à preparação de drogas].

Sobre isso: "PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. POSSE DE INSUMO (CAFEÍNA) DESTINADO À PREPARAÇÃO DE DROGAS. CONDUTA MATERIALMENTE TÍPICA (grifei). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. REEXAME DE FATOS. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a cafeína constitui INSUMO (grifei) comumente utilizado para aumentar a quantidade e o volume de entorpecentes. Sendo assim, sua posse para tal finalidade configura o delito do art. 33, § 1º, I, da Lei n. 11.343/2006 (grifei). 3. Conforme pontuou julgado da Sexta Turma, "[...] a expressão 'matéria-prima' abrange não só as substâncias destinadas exclusivamente à preparação de drogas, mas também aquelas que, eventualmente, se prestam a esse objetivo" (HC 45.003/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 26/10/2009). 4. A pretensão de absolvição por insuficiência de prova demanda, in casu, o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de habeas corpus. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 441695-sp - 5 Turma - Ministro Ribeiro Dantas - Julgamento - 15/10/2019).

E ainda: "PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. POSSE DE INSUMO (CAFEÍNA) DESTINADO À PREPARAÇÃO DE DROGAS. CONDUTA MATERIALMENTE TÍPICA [...] É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a cafeína constitui insumo comumente utilizado para aumentar a quantidade e o volume de entorpecentes. Sendo assim, sua posse para tal finalidade configura o delito do art. 33, § 1º, I, da Lei n. 11.343/2006. 3. Conforme pontuou julgado da Sexta Turma, "[...] a expressão 'matéria-prima' abrange não só as substâncias destinadas exclusivamente à preparação de drogas, mas também aquelas que, eventualmente, se prestam a esse objetivo" (HC 45.003/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 26/10/2009). 4. A pretensão de absolvição por insuficiência de prova demanda, in casu, o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de habeas corpus. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 441.695/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019).

Ademais, a acusada LUCIANA, não obstante a continuidade de diligência decorrente do estado flagrancial, cuidando-se de delito de natureza permanente, autorizou o ingresso dos Policiais Militares em sua moradia, consoante ela mesma indicou, não havendo, portanto, se falar em vício de consentimento, inexistindo qualquer elemento a indicar situação que aviltasse a autorização.

E também a denúncia anônima não maculou as diligências que se seguiram.

Entendimento recente do Egrégio Supremo Tribunal Federal aponta ser possível a comunicação anônima.

Sobre isto: "Agravos regimentais em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. 4. Deflagração da persecução penal pela chamada "denúncia anônima". Possibilidade. 5. Ulteriores diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados. 6. Alegação de ofensa aos princípios constitucionais do artigo 5º, incisos LIV e LVI. 7. Necessidade de reexame fático-probatório que encontra óbice na Súmula 279/STF. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE 1069179 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-153, 01-08-2018)

Deste modo, ficam superadas as objeções deduzidas.

E a autoria atribuída aos acusados é certa.

Conquanto tenha permanecido em silêncio contemporaneamente aos fatos, quando ouvido

em Juízo o acusado EDSON afirmou que estava no interior de sua moradia quando notou uma movimentação defronte ao seu portão e depois no interior do imóvel, por isto empreendeu fuga, receando alguma ação criminosa, havendo no bairro registro de diversos homicídios. Acrescentou que não foi possível verificar que se tratavam de Policiais, já que não se identificaram antes e não conseguiu enxergá-los de onde estava. Posteriormente acabou abordado na rua atrás do imóvel e, de fato, em seguida apreenderam em sua residência uma balança, além de eppendorfs vazios. Acrescentou que então foi conduzido a outro endereço, onde foi apreendido entorpecente. Esclareceu que exercia a função de motoboy e, diante da falta de serviço, recebeu proposta para armazenar consigo os eppendorfs por quinze ou vinte dias pela quantia de oitenta reais. Por fim, negou ter admitido a prática delitiva para os Policiais ou ter informado outro endereço a eles, durante as diligências, inclusive relatando que não conhece LUCIANA (fls. 318).

A acusada LUCIANA, igualmente ouvida em juízo, afirmou que na ocasião dos fatos estava em seu apartamento, quando alguns Policiais chegaram ao local com a informação de que por lá residia pessoa de nome André, isto sendo indicado pelo acusado EDSON. Afirmou que não conhecia este corréu e também desconhecia o fato de estar sendo procurada pela justiça -- apenas tendo conhecimento de que estava em prisão domiciliar --, igualmente desconhecendo a existência de entorpecente em sua moradia, com a observação de que não autorizou o ingresso dos Policiais no imóvel (fls. 318).

Todavia, a versão deduzida pelos acusados foi contrariada pela prova produzida. De fato, o Policial Militar Newton esclareceu que à época dos fatos recebeu informação de um popular, que não quis se identificar, esclarecendo que, em determinado imóvel, com endereço indicado, no bairro Jardim Brasília, estaria sendo armazenada e fracionada grande quantidade de entorpecente por um indivíduo, cujas características foram fornecidas, com fluxo intenso de pessoas no local no período noturno. Diante destas informações, a fim de averiguar a denúncia, em diligências pelo local, avistaram o acusado EDSON, na via pública, carregando consigo uma sacola, que cuidou em dispensar logo que notou a aproximação da guarnição, adentrando em seguida na moradia anteriormente indicada, onde subiu no telhado do imóvel, mas acabou abordado quando alcançou novamente a via pública aos fundos do mesmo imóvel. Ainda segundo o exposto, foi então apreendida a sacola dispensada, onde acondicionada certa quantidade de cocaína. Diante destas circunstâncias, ingressaram no imóvel e localizaram na pia da cozinha outra quantidade de cocaína, alguns eppendorfs vazios, outros contendo cocaína, além de liquidificador, peneira e outros petrechos para o fracionamento de entorpecente. Em seguida uma outra equipe policial passou a diligenciar em um outro endereço indicado por EDSON, após ter admitido prática delitiva, situado em um condomínio, no bairro Chácara Luza, onde foi apreendida outra quantidade maior de entorpecente, sendo presa no local a acusada LUCIANA, que estava sendo procurada por tráfico ilícito de entorpecentes e foi indicada por EDSON como a pessoa que fazia o armazenamento de maior quantidade da substância ilícita, enquanto ele realizava o fracionamento. Acrescentou o depoente que o imóvel onde EDSON foi abordado não continha estrutura de moradia, aparentando ser um imóvel abandonado, apenas com um colchão no chão e alimentos na cozinha, não se recordando de qualquer apreensão de cafeína, na localidade (fls. 318).

....

A testemunha Paulo, também Policial Militar, relatou que seu colega de corporação recebeu a informação de que quantidade de entorpecente estaria sendo armazenada e fracionada em um imóvel situado no bairro Jardim Brasília, nesta Comarca. No endereço indicado, avistou-se um indivíduo que, com a aproximação da viatura, dispensou uma sacola na via pública e adentrou naquela residência, onde subiu no telhado, sendo, por fim, abordado na rua de trás do imóvel. Na sacola anteriormente dispensada foram apreendidas porções de cocaína e, no interior da moradia outra quantidade de entorpecente, com as mesmas características daquelas porções inicialmente localizadas, bem como petrechos como alguns eppendorfs vazios e outros cheios, balança de precisão e peneiras. Ao ser indagado sobre as apreensões, o acusado admitiu que tinha a função de fracionar o entorpecente para

que fosse posteriormente comercializado, acrescentando que outra quantidade da substância ilícita estaria armazenada em outro endereço, em um condomínio. Em diligências por este segundo local, foram atendidos por LUCIANA, a qual acabou admitindo a existência de entorpecente na moradia, observando que pertencia a seu marido "André" -- que foi identificado, porém não localizado --, que respondia a processo por tráfico ilícito de entorpecentes. Na moradia foram em seguida apreendidos tijolos de cocaína, maconha -- que se encontravam no quarto do casal --, além de balanças de precisão, ressaltando que a acusada LUCIANA respondia a dois outros processos em que se lhe imputa a prática do mesmo delito, sendo procurada pela justiça (fls. 318).

No mesmo sentido o depoimento dos policiais militares Ronmagson e Valdir, este último informando que a acusada, quando inicialmente abordada, deduziu falsa identidade, mas posteriormente declinou o verdadeiro nome, constatando-se que havia dois mandados de prisão expedidos em desfavor dela, também em razão de tráfico de entorpecentes (fls. 318).

Acresça-se que, como se tem reiteradamente sustentado, à míngua de elemento que demonstre efetivamente algum abuso, não há de se desmerecer o depoimento dos policiais envolvidos na diligência.

A propósito: "os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais que oferecem a seus superiores e à justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes" (in Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e Outros, 3ª ed., RT, p.1829).

Ademais, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54).

Acresça-se que "é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (RT 530/372).

E, ainda: "cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva. Não é suficiente a mera alegação por simplesmente serem os depoentes policiais" (Apelação nº 990.09.216746-4, TJSP, Rel. Salles Abreu). Deste modo, os elementos probatórios produzidos permitem seguro juízo de convicção sobre o armazenamento da matéria-prima destinada a preparação, como também do próprio entorpecente, este apreendido na moradia de LUCIANA, bem como sobre sua destinação mercantil, não apenas em função da quantidade apreendida, como também em razão das circunstâncias relacionadas à apreensão -- informação dando conta de que pessoa com as mesmas características físicas do acusado, no endereço do imóvel por ele ocupado, estava envolvido com a mercancia ilícita; início de fuga de EDSO, inclusive tendo pulado telhado de imóveis contíguos aquele por ele ocupado; apreensão de petrechos, no interior a moradia dele, inclusive com resquícios de pó branco, além da apreensão de eppendorfs, comumente utilizados para armazenamento de entorpecente, e cafeína, insumo utilizado na mistura da droga para aumento da quantidade e do volume; indicação realizada por EDSO do endereço e identificação da acusada LUCIANA; e a efetiva apreensão de entorpecente na moradia da acusada. Isto considerado, passo à dosagem da pena.

Considerando o disposto no artigo 59, do Código Penal, e artigo 42 da Lei de Tóxicos, e diante da quantidade de substância entorpecente apreendida, além de insumos para o incremento do comércio ilícito, revelando atividade intensa e organizada, deve a pena base ser fixada a ambos acima do mínimo legal em 6 (seis)

anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

A pena base, entretanto, deve ser agravada em 1/6 (um sexto), por conta da recidiva de ambos os acusados (fls. 197/198, 202/204 e 315/316), totalizando 7 (sete) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, estes no valor unitário mínimo, em razão da situação econômica dos acusados.

Por fim, diante do entendimento firmado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, de que não caracteriza ofensa ao princípio do non bis in idem, a recidiva também afasta objetivamente a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e, com fundamento no artigo 33, "caput", e § 1º, inciso I, da Lei nº 11.343/06, c.c. as disposições da Lei nº 8.072/90, CONDENO os acusados LUCIANA GORETTE VIANA e EDSON LORRAN BEZERRA RAMOS à pena de 7 (sete) anos reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, diante da situação econômica dos acusados, corrigido desde a época do fato.

Sobre o regime inicial de cumprimento das penas, devem ser consideradas as recidivas e também a natureza hedionda do delito, por equiparação, atendendo comando constitucional (art. 5º, XLIII, CF), dispondo o artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.464/07, que deve a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado, introduzindo a progressividade, a fim de sanar vício da redação inicial que determinava o integral cumprimento da sanção em regime prisional fechado, o que atentaria contra o princípio da individualização da pena.

Não se ignora que, ainda esta alteração, com disposição de início em regime fechado, foi também considerada inconstitucional, em caráter incidenter tantum, no HC nº 111.464/ES, sendo Relator o Ministro Dias Toffoli, por maioria de votos, entendendo-se padecer do mesmo vício de violação ao princípio da individualização da pena, devendo ser fixado o regime prisional, mesmo em se tratando de delitos hediondos e equiparados, na forma do artigo 33, § 2º, alíneas "b" e "c", do Código Penal.

Nada obstante a autoridade da mencionada decisão, promanada do Pretório Excelso, em controle difuso, reconhecendo incidentalmente a inconstitucionalidade, e considerando a controvérsia que marca a questão, até mesmo no âmbito da Suprema Corte, já que a decisão foi tomada por maioria de votos, possível dizer, com a mais elevada vênia, que em função do comando previsto no artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, cuidou o legislador infraconstitucional em estabelecer tratamento mais rigoroso para o cumprimento da pena de alguns delitos (hediondos e equiparados) dada a maior gravidade da violação aos bens juridicamente protegidos, por isto se estabelecendo no artigo 2º, §1º, da Lei nº 8072/90, com a alteração dada pela Lei nº 11.464/07, que as penas seriam cumpridas em regime prisional inicial fechado.

Não se entende, renovada a vênia, tenha a disposição legal violado o princípio da individualização da pena, porquanto, não obstante a limitação ao regime inicial mais gravoso, como ocorre em situações outras, dada a valoração legitimamente exercida pela atividade legislativa, tendo como fonte o anseio de se reprovar de forma distinta ações delitivas que causam maior perturbação ao meio social, não se tem por interdita a progressividade no cumprimento da pena, tampouco os benefícios do livramento condicional e a remissão, o que assegura a individualização da sanção, sem descurar de suas funções retributivas e preventivas, além de ressocializadoras. Como se tem objetado, se o regime inicial obrigatoriamente fechado é inconstitucional, por conta de critérios qualitativos (crimes hediondos e equiparados), também o seria pelo critério quantitativo da regra prevista no artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, que prevê obrigatoriamente regime prisional inicial fechado no caso de pena superior a 8 (oito) anos.

Além disto, submetendo a individualização da pena em casos de delito hediondo ou equiparado tão somente às regras gerais previstas no artigo 33, §2º, do Código Penal, estar-se-ia retirando eficácia do comando inserto na Constituição Federal que determinou a adoção de tratamento diferenciado mais rigoroso nestas hipóteses

(cf. art. 5º, LXIII, CF).

Deste modo, as penas cominadas aos acusados deverão ser inicialmente cumpridas em regime prisional fechado, não se lhes facultando a interposição de recurso em liberdade, já que persistem os fundamentos que determinaram as prisões cautelares, potencializados pela sentença condenatória, sem prejuízo de eventual progressão em sede de execução provisória.

A propósito: "O direito de apelar em liberdade de sentença condenatória não se aplica ao réu já preso, desde o início da instrução criminal, em decorrência de flagrante ou de preventiva. A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência (Súmula nº 9, do STJ)" (HC nº 86907/RS, Rel. Min. Felix Fisher, DJU. 14.04.2008, p.1).

E, especificamente aqui, "a apelação em liberdade prevista no art.59 da Lei nº 11.343/06 pressupõe a cumulação dos pressupostos da primariedade e da inexistência de antecedentes com o fato de ter o réu respondido em liberdade a ação penal, tanto pela inoccorrência de prisão oriunda de flagrante delito quanto pela inexistência de decreto de prisão preventiva" (HC - Agr. 94.521/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 1º.08.2008). E, por fim: "o agente que responde a todo o processo por tráfico ilícito de entorpecente preso não tem o direito de aguardar o recurso interposto pelo Órgão Ministerial em liberdade, mesmo tendo a sentença contra si prolatada substituído a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária e serviços à comunidade, eis que a efetividade imediata da pena substitutiva, configuraria em execução provisória" (TJSP, HC 387.079-3/4, 5ª Câmara, Rel. Des. Gomes de Amorim, v.u., RT807/605, apud RENATO Marcão, Tóxicos, 4ª ed.p.527). Por fim, diante do quantum das penas aplicadas, não incide as disposições previstas no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal.

Recomendem-se os acusados nas prisões em que se encontram e, oportunamente, promovam-se os registros das condenações definitivas no sistema informatizado da serventia, comunicando-se o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (I.I.R.G.D.).

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Rio Claro, 22 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA